

<제7장 취소소송의 가구제.제1절 집행정지>

I. 집행정지의 의의

1. 개념[행소법 제23조 제2항]

- 집행정지란 행정소송이 제기된 처분의 효력이나 그 집행, 또는 절차의 속행을 종국 판결이 있을 때까지 잠정적으로 정지시키는 제도를 말한다. 행정소송법 제23조 제2항은 취소소송이 제기된 경우에 처분등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인하여 생길 회복하기 어려운 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있다고 인정할 때에는 본안이 계속되고 있는 법원은 당사자의 신청 또는 직권에 의하여 처분등의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행의 전부 또는 일부의 정지를 결정할 수 있다.고 규정하여 집행정지의 개념과 요건을 명시한다. 집행정지는 행정의 공정력으로 인해 취소소송 제기만으로는 처분의 효력이 정지되지 않는다는 집행부정지의 원칙에 대한 예외로서, 국민의 권리 구제 실효성을 확보하기 위한 수단이다.

2. 현행법의 태도

- 현행 행정소송법은 집행정지 제도를 명문으로 규정함으로써, 소송 제기만으로는 처분의 효력이 정지되지 않는다는 집행부정지의 원칙을 채택하고 있다. 이는 행정의 집행력과 공정력을 존중하고 행정의 효율성을 유지하려는 취지이다. 그러나 이 원칙을 무한정 관철할 경우, 본안 판결이 확정될 때까지 처분이 집행되어 당사자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 수 있다. 따라서 현행법은 집행부정지의 원칙을 고수하면서도, 일정 요건 하에 법원이 직권 또는 신청에 의해 집행정지 결정을 내릴 수 있도록 하여 사익 보호와 공익 보호의 균형을 도모하고 있다. 법원은 집행정지 결정을 통해 본안 소송의 승소 가능성이 있는 당사자에게 잠정적인 구제를 제공하여 행정소송 제도의 실질적인 기능을 강화한다.

II. 집행정지의 요건

- 집행정지 결정은 다음과 같은 적극적 요건과 소극적 요건을 모두 충족할 때 가능하다.

1. 적극적 요건[행소법 제23조 제2항]

(1) 본안 소송의 계속

- 집행정지는 본안 소송의 부수 절차이므로, 취소소송이 적법하게 제기되어 법원에 계속되어 있어야 한다. 본안 소송의 청구 자체가 부적법하여 각하될 가능성이 명백한 경우에는 집행정지 신청은 부적법하게 된다. 다만, 본안 청구가 이유 없음이 명백하더라도 집행정지 요건의 충족 여부와는 직접적인 관계가 없으며, 이는 뒤에서 설명할 소극적 요건과 연관된다.

(2) 처분등의 존재

- 집행정지의 대상이 되는 행정 처분 또는 재결이 존재하여야 한다. 이는 처분의 집행이나 효력을 정지하는 것이 목적이므로, 집행이 완료되었거나 효력이 소멸된 처분에 대해서는 집행정지를 구할 실익이 없어 부적법하다.

(3) 회복하기 어려운 손해 발생 우려

- 처분 등이나 그 집행 또는 절차의 속행으로 인해 당사자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어야 한다. 여기서 회복하기 어려운 손해란 금전으로 보상이 불가능하거나, 금전 보상으로는 충분한 구제를 받을 수 없는 유·무형의 손해를 의미한다. 단순히 손해가 발생한다는 것만으로는 부족하며, 손해를 금전 배상으로 전보하는 것이 가능하더라도, 그 손해를 참고 본안 판결을 기다리는 것이 사회 통념상 현저히 곤란하다고 인정되는 경우도 포함된다.

(4) 긴급한 필요

- 손해를 예방하기 위하여 긴급한 필요가 있어야 한다. 이는 본안 판결을 기다릴 만한 시간적 여유가 없으며, 즉시 집행정지 결정을 내리지 않으면 회복하기 어려운 손해가 발생하거나 확대될 우려가 있다는 것을 의미한다.

2. 소극적 요건

(1) 공공복리에 중대한 영향 미칠 우려가 없을 것[행소법 제23조 제3항]

- 집행정지 결정으로 인해 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있어서는 안 된다. 법원은 집행정지 신청을 심리할 때, 신청인의 사익 보호 필요성과 집행정지로 인해 발생할 수 있는 공익 침해의 정도를 형량하여야 한다. 사익 보호의 필요성이 공익 침해의 우려보다 크지 않다면 집행정지 신청은 기각된다. 여기서 공공복리는 단순한 공익이 아니라, 집행정지를 통해 발생하는 영향이 사회 일반의 이익에 중대하고 회복하기 어려운 결과를 초래할 정도의 공익을 의미한다.

(2) 본안 청구가 이유 없음이 명백하지 않을 것[판례]

- 판례는 집행정지 신청 시 본안 청구의 이유 유무에 대한 소명을 요구하지는 않지만, 본안 청구가 이유 없음이 명백한 경우에는 집행정지를 허용할 필요성이 없으므로, 이러한 경우를 소극적 요건으로 간주하여 집행정지를 불허한다. 여기서 이유 없음이 명백한 경우란 본안에서 원고가 승소할 가능성이 전혀 없다는 것이 명백히 드러나는 경우를 말한다.

III. 집행정지결정

1. 신청 및 법원의 직권 발동

- 집행정지는 원칙적으로 당사자의 신청에 의해 이루어지지만, 법원은 직권으로도 집행정지 결정을 할 수 있다.

2. 관할 법원

- 집행정지 결정은 본안이 계속되고 있는 법원이 관할한다. 본안 소송이 고등법원이나 대법원에 계류 중인 경우에도 해당 법원이 관할 법원이 된다.

3. 심리 방식

- 집행정지는 결정의 형식으로 이루어진다. 법원은 심리 시 당사자의 주장과 관계 서류를 검토하는 것이 일반적이며, 필요하다고 인정하는 경우에는 당사자를 신문할 수 있다. 심리는 변론을 거치지 않고 이루어지는 것이 원칙이다.

4. 법원의 판단

- 법원은 집행정지 요건의 충족 여부를 종합적으로 판단하여, 요건이 충족되면 집행정지 결정을 하고, 요건이 충족되지 않거나 소극적 요건에 해당하면 집행정지 신청을 기각한다.

IV. 집행정지결정의 내용

- 법원은 집행정지 신청을 인용하는 경우, 처분의 효력, 처분의 집행, 절차의 속행 중에서 필요한 범위 내에서 그 전부 또는 일부를 정지할 수 있다.

1. 처분의 효력정지

- 처분의 효력정지란 처분의 법률적 효과 발생을 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 이는 세 가지 정지 형태 중 가장 강력한 효력을 가지며, 그 효과는 본안 소송에서 취소 판결이 내려진 것과 유사하다. 법원은 처분의 집행정지 또는 절차의 속행정지만으로 그 목적을 달성할 수 있는 경우에는 효력정지를 허용하지 않는다. 이는 행정의 공정력을 최대한 유지하려는 취지이다.

2. 처분의 집행정지

- 처분의 집행정지란 처분으로 인해 발생한 집행 행위 또는 강제 집행 절차를 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 예를 들어 납세 고지 처분의 효력은 유지되지만, 그에 따른 재산 압류 등 강제 징수 절차는 정지된다.

3. 절차의 속행정지

- 절차의 속행정지란 처분으로 인해 후속적으로 이어지는 행정 절차의 진행을 잠정적으로 정지시키는 것을 말한다. 예를 들어 징계 처분이 내려진 후 징계 절차에 따른 다음 단계의 조치를 정지시키는 것이다.

V. 집행정지의 효력

1. 형성력

- 집행정지 결정은 처분의 효력, 처분의 집행, 절차의 속행을 잠정적으로 정지시킨다는 점에서 형성력을 가진다. 그러나 이는 본안 판결의 형성력처럼 처분의 효력을 소급하여 상실시키는 것이 아니라, 장래를 향하여 그 작용을 잠정적으로 정지시키는 일시적인 효력을 가진다.

2. 기속력

- 집행정지 결정은 결정의 내용에 따라 피고인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 기속력을 가진다. 행정청은 집행정지 결정의 취지에 반하여 처분의 집행을 계속하거나, 정지된 절차를 속행하는 등 위반되는 행위를 할 수 없다. 이러한 기속력은 집행정지 결정의 실효성을 확보하는 중요한 근거가 된다.

3. 시간적 효력

- 집행정지의 효력은 결정이 있는 때부터 발생하며, 중국 판결이 확정될 때까지 지속되는 것이 원칙이다. 다만, 법원은 결정에서 정지 기간을 따로 정할 수도 있다. 집행정지 결정의 효력은 본안 소송에서 각하나 기각 판결이 선고되면 특별한 사정이 없는 한 소멸한다. 이는 본안 판결이 정지된 처분의 위법성이 없음을 최종적으로 확정했기 때문이다.

VI. 집행정지결정에 대한 불복[행소법 제23조 제5항]

1. 즉시항고

- 행정소송법 제23조 제5항 전문은 집행정지 결정 또는 기각 결정에 대하여 불복이 있는 당사자는 즉시항고를 할 수 있도록 규정한다. 즉시항고는 법원의 집행정지 결정에 대한 신속한 상급심의 판단을 받기 위한 제도이다.

2. 항고의 효력

- 행정소송법 제23조 제5항 후문은 즉시항고가 제기되더라도 그 항고는 집행정지 결정의 집행을 정지하는 효력이 없다는 것을 규정한다. 즉, 집행정지의 효력은 유지된다는 뜻이다. 이는 집행정지의 목적인 긴급한 사익 보호를 우선하기 위한 조치이다. 다만, 항고 법원은 집행정지 결정의 집행을 정지할 필요가 있다고 인정하는 경우, 직권으로 항고 법원이 집행을 정지시킬 수는 있다.

VI. 집행정지결정의 취소[행소법 제24조 제1항·제2항, 제23조 제4항]

1. 취소 사유

- 집행정지 결정은 잠정적인 효력을 가지므로, 그 결정의 기초가 된 사유가 소멸되거나 변경된 경우 법원은 이를 취소할 수 있다. 행정소송법 제24조 제1항은 집행정지 결정 후에 집행정지 사유가 소멸되거나, 사정 변경으로 인해 집행정지 결정의 유지가 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 판단될 때, 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 의해 집행정지 결정을 취소할 수 있도록 규정한다.

2. 취소 절차 및 불복

- 행정소송법 제24조 제2항은 집행정지 결정의 취소 결정에 대하여도 즉시항고를 할 수 있도록 규정한다. 이는 당사자의 권리 구제 기회를 보장하기 위함이다. 이 때에도 행정소송법 제23조 제4항을 준용하여 그 이유를 소명하여야 한다.

VII. 결론

- 집행정지는 행정소송의 집행부정지원칙에 대한 예외로서, 본안 소송 계속, 회복하기 어려운 손해 발생 우려, 긴급한 필요 등의 적극적 요건과 공공복리에 중대한 영향 미칠 우려가 없을 것이라는 소극적 요건이 충족될 때 법원의 결정으로 이루어진다. 그 내용은 효력, 집행, 절차의 속행 정지 중 필요한 범위에서 정해지며, 결정은 형성력과 기속력을 가진다. 결정에 대한 불복은 즉시항고로 가능하며, 사정 변경 시에는 법원이 직권이나 신청에 의해 결정을 취소할 수 있다. 집행정지 제도는 신속한 사익 보호를 통해 행정소송의 실효성을 높이는 핵심적인 가구제 수단이다.